

身分犯の共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので、目的犯に当たる犯罪行為を、当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合、同条の適用の余地はない。
2. 刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。
3. 非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合、当該非占有者には、刑法第65条第1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し、同条第2項の適用により単純横領罪の刑が科される。
4. 刑法第65条の身分は、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態の全てを指称するものであるので、責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合、同条が適用される。
5. 自首による刑の減免は一身的な事由であるので、共犯者のうち一人に自首が成立する場合、刑法第65条第1項の適用はなく、その減免の効果は自首した者以外には及ばない。

№173	身分犯の共犯	正答率
共通R 1-19	正解	75%
	3、5（順不同）	

1 誤っている

本記述前段について、「身分」とは、「男女の性別内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」をいい（最判昭27.9.19）、犯人の一時的な状態も含まれる。よって、本記述前段は誤っている。本記述後段について、最判昭42.3.7（百選I93事件）は、麻薬輸入罪における「営利の目的」は、麻薬取締法の「規定に違反して麻薬を輸入した者に対しても、犯人が営利の目的をもつていたか否か」という犯人の特殊な状態の差異によつて、各犯人に科すべき刑に軽重の区別をしているものであつて、刑法65条2項にいう『身分二因り特二刑ノ軽重アルトキ』に当るものと解するのが相当であり、「身分」に該当し、65条2項の適用があるとしている。よって、本記述後段も誤っている。

2 誤っている

大判大3.5.18は、常習賭博の刑を加重した理由は本来博徒を厳罰に処してこの種の犯罪を鎮圧する趣旨であるが、常習として賭博を教唆するものこれと処罰を異にするものではないし、また法文上も特段の妨げはないとして、常習性を有する教唆者又は幫助者に65条2項が適用されるとしている。したがって、本記述は誤っている。

3 正しい

最判昭32.11.19（百選I94事件）は、非占有者の業務上横領罪の行為につき、「業務に従事していたことは認められないから、刑法65条1項により……該当する業務上横領罪の共同正犯として論ずべきものである」とし、また、業務上横領罪について、単純横領罪よりも「とくに重い刑を科することを規定したものである」から、65条2項により単純横領罪の刑を科すべきであるとしている。よって、判例によれば、非占有者の業務上横領罪の行為について65条1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し、同条2項の適用により単純横領罪の刑が科される。

4 誤っている

本記述前段について、「身分」とは、「男女の性別内外国人の別、親族関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態」をいう（最判昭27.9.19）。よって、本記述前段は正しい。本記述後段について、刑事未成年か否かは、有責性で検討されるものであつて特定の構成要件の内容になつておらず、全ての犯罪行為に関するものである（41条）から、本記述の場合に65条2項は適用されない。よって、本記述後段は誤っている。

5 正しい

42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減輕することができる」としている。その趣旨は、犯罪の捜査を容易にするためという政策的理由及び改悔による非難の減少に基づくことにある。このような趣旨からすれば、42条1項の適用は一身的な事情であるといえ、その適用は、個別的に検討することになる。他方で、65条は、本質的に同一の根拠により一身的な事情が共犯の成否に影響するすべての場合に援用されるものである。よって、42条1項の適用は、一身的な事情であるが、共犯の成否に影響は及ぼさないため、共犯者のうち一人に自首が成立する場合、65条1項の適用はない。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述は3と5であり、したがって、正解は肢3と肢5（順不同）となる。